

1513849-62.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... sendo certamente destinada ao tráfico de drogas.

O réu, ademais, não comprovou o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, a presumir que praticava o tráfico para se manter.

Assim, é certo que o entorpecente encontrado se destinava à venda, autorizando a prolação de um decreto condenatório.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513849-62.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513849-62.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158052/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 12150870 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 992/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2158052 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER PAIVA FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

VALTER PAIVA FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, II, "j" do Código Penal, porque, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 13h30min, na Av. Deputado Emílio Carlos, altura do numeral 2300, Limão, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo, 10 (dez) porções de cocaína em envelopes, com peso líquido de 7,9g (sete gramas e nove decigramas); 20 (vinte) porções de cocaína em eppendorfs, com peso líquido de 7,7g (sete grama e sete decigramas); 17 (dezesete) porções de cocaína na forma de crack, embaladas em invólucros plásticos, com peso líquido de 5,3g (cinco gramas e três decigramas); 02 (duas) porções de drogas contendo Tetrahydrocannabinol (THC), na forma popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 1,5g (um grama e dois decigramas); 19 (dezenove) porções de drogas contendo Tetrahydrocannabinol (THC), na forma popularmente conhecida como maconha, em trouxinhas com formatos de tiras, com peso

líquido de 121,8g (cento e vinte e um gramas e oito decigramas); 98 (noventa e oito) porções de drogas contendo Tetrahydrocannabinol (THC), na forma popularmente conhecida como maconha, em trouxinhas, com peso líquido/ de 120,7g (cento e vinte gramas e sete decigramas) e; 01 (uma) porção de drogas contendo Tetrahydrocannabinol (THC), na forma popularmente conhecida como maconha, em um invólucro plástico, com peso líquido de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentada em favor do réu a resposta a que alude o art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 133/134). A denúncia foi recebida (fls. 189/190). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas por ambas as partes, sendo em seguida o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, afastando-se, todavia, a agravante da calamidade pública (v. fls. 219/223).

A defesa do acusado pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (fls. 223/224).

É o Relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelos laudos periciais (fls. 121/124 e fls. 125/128), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos e repousa sobre o acusado.

A testemunha arrolada por ambas as partes, Rafael Nunes Ribeiro, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estaria investigando uma denúncia envolvendo o réu, a qual o colocava como sendo o gerente do tráfico na comunidade do Boi Malhado, sendo que, ao efetuar a abordagem, localizou uma bolsa no interior do veículo do acusado, contendo diversas porções de maconha, cocaína e crack. Em sentido similar foi o depoimento do policial militar Júlio César de Lima Prado (v. mídia).

Em seu interrogatório, o acusado, Valter Paiva Farias, negou a prática delitiva. Narrou que os policiais surgiram na delegacia com uma bolsa contendo substâncias entorpecentes e atribuindo a ele a propriedade da mesma (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado realmente era o proprietário da droga apreendida, a qual se destinaria à comercialização.

Convém ainda ressaltar que os depoimentos das testemunhas policiais, como tem reiteradamente se manifestado a jurisprudência, não podem ser desconsiderados pelo simples fato de serem policiais. Não havendo qualquer indício nos autos quanto a suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova. O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/54).

O réu, por sua vez, apresentou versão inverossímil, limitando-se a negar a propriedade da substância entorpecente, restando tal alegação, isolada dos demais elementos de prova colacionados no presente feito.

Também é certo que a quantidade de entorpecente apreendida é muito superior à quantidade normalmente encontrada com meros usuários, sendo certamente destinada ao tráfico de drogas.

O réu, ademais, não comprovou o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, a presumir que praticava o tráfico para se manter.

Assim, é certo que o entorpecente encontrado se destinava à venda, autorizando a prolação de um decreto condenatório.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, passo à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ressalto que tal fator de aumento se mostra devido ante a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Na segunda fase, observo que o acusado é tecnicamente primário. Ademais, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Recurso ministerial. Dosimetria da pena. Pleito de aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

Impossibilidade. Quantidade de drogas que não se revelou expressiva (139,0g de maconha, 111,0g de crack, 11,7g de cocaína e 200ml de lança-perfume). Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas.

Confissão judicial do acusado. Dosimetria. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Pena majorada na primeira etapa, em razão dos maus antecedentes do acusado. Condenações que configuram reincidência e devem ser sopesadas na segunda etapa. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito de afastamento da agravante previsto no artigo 61, inciso II, alínea j, do CP. Possibilidade.

Inexistência de indícios de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública. Agravante afastada.

Pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Réu que ostenta duas condenações caracterizadoras de reincidência. Quantum da pena e reincidência do agente que impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - APR: 15129428720208260228 SP 1512942-87.2020.8.26.0228, Relator: Leme Garcia, Data de

Julgamento: 02/02/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2021).

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, diante da expressiva quantidade de drogas encontrada, é lícito presumir que atuava com regularidade nesta atividade, não merecendo, portanto, ser brandamente apenado.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitivas as penas anteriormente fixadas.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Assim foi redigida a ementa do

julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente. (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito erga omnes, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma

empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 1º, "a" c/c artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALTER PAIVA FARIAS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicial semiaberto.

Faculto o recurso em liberdade.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- i) Expeça-se guia para a execução definitiva da pena.
- ii) Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do art. 15, inciso III da Constituição Federal;
- iii) Oficie-se a Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

P.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA